

1500625-40.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... ostensivo visando combater o tráfico de drogas. Neste sentido, destaco recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de Drogas - Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Bairro dos Alemães, Piracicaba - 13419-100 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500625-40.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2114993/2022 - 01º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO ALVES BAPTISTA

Réu Preso

Contr. nº 2022/000502

Aos 08 de agosto de 2022, às 13:30 horas, por meio de audiência virtual realizada pelo aplicativo Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e 208/22 e em observância ao Provimento CSM 2651/2022 e a Resolução 850/21, da 1ª Vara Criminal do Foro de Piracicaba, Comarca de Piracicaba, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira, comigo assistente judiciária ao final nomeada, o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Antonio Carlos Perez Antunes da Silva foi aberta a tele-audiência para instrução, debates e julgamento nos autos da ação supra.

Presente o réu PAULO SÉRGIO ALVES BAPTISTA (preso CDP Piracicaba). Presente a Defensoria Pública na pessoa do Dr. Luiz Antonio Felipe Franchito. Presente(s) a(s) testemunha(s) comuns: GM Franscico Dernival Miranda Junior e GM Juvenal Estevão de Macedo

Antes do início da audiência foi (foram) realizada(s) fotografia(s) do(s) documento(s) de identificação exibidos pela(s) testemunha(s), o que foi aceito pelas partes, (imagem(ns) exibida(s) durante audiência).

INICIADOS OS TRABALHOS, foi assegurada à defesa oportunidade para entrevista reservada com o(a) acusad(a) e todos os presentes foram retirados da sala, inclusive a M.M. Juíza, seu(sua) assistente e o Promotor de Justiça, de modo a não terem acesso a conversa privada entre o(a) ré(u) e sua defesa.

Pela MM. Juíza foi consignado que: "As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que não ouçam os depoimentos umas das outras, assim, conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 210 do CPP".

Após a identificação pessoal, o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela(s) parte(s) (GM Francisco) e em seguida o interrogatório do réu foi captado e gravado em áudio e vídeo.

Dada a palavra ao Dr. Promotor e a Defesa pelos mesmos foi dito que desistiam da oitiva(s) da(s) testemunha(s) GM Juvenal, o que foi homologado pelo(a) MM. Juiz(a). A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem para requerimentos acerca de eventuais diligências. Dada a palavra ao Ministério Público e Defesa(s), nada foi requerido. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi determinado que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). PAULO SÉRGIO ALVES BAPTISTA, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois no dia 28 de abril de 2022, por volta das 09h00, na Rua Tiradentes, nº 892, Bairro Centro, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16,5g de cocaína, distribuídos em 64 invólucros, 8,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 149 invólucros¹, substâncias entorpecentes as quais determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (fls. 107/110). O réu foi notificado, a denúncia foi recebida e durante a instrução prestaram depoimento as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, o réu interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade delitiva foi confirmada nos autos pelo auto de exibição e apreensão a fl. 10/12, foto a fls. 13/16 e laudo pericial a fls. 134/136. Da mesma forma, comprovada a autoria delitiva. De fato, o guarda relatou, na fase informativa (fls. 02), que “estava-se em regular atividade funcional, acompanhado do colega de farda MACEDO, fazendo uso da viatura ROMU-92, efetuando patrulhamento de rotina pela área central desta cidade. O depoente afirma que transitavam pela Rua Tiradentes quando foi notada presença de um indivíduo quando deixava o interior de um imóvel e seguiu caminhando pelo logradouro público, o qual demonstrou certo nervosismo ao perceber a presença dos agentes, verificando-se que ele trazia certo volume na cintura, razão pela qual foi abordado. Restou encontrado na veste íntima do indivíduo posteriormente identificado como PAULO SERGIO ALVES BAPTISTA, 37 anos de idade, uma garrafa pet de tamanho pequeno de refrigerante, marca coca-cola, vedada por tampa, contendo em seu interior 123 (cento e vinte e três) porções de “crack”, adrede preparadas e prontas para o comércio. O infrator trazia no bolso da bermuda a quantia pecuniária de R\$ 70,00 (setenta reais), em cédulas de miúdas de 2,00 (dois reais). Diante das evidências o autor admitiu a posse e propriedade do entorpecente e confessou que se destinava ao comércio ilícito, acrescentando que desenvolvia a mercancia numa praça pelas imediações do terminal central de integração de ônibus coletivo, frisando que estava a caminho daquele local com intuito de vender a droga. O investigado foi interpelado a respeito do imóvel de onde havia acabado de sair e revelou que se tratava de uma casa abandonada por ele ocupada recentemente, acrescentando que mantinha outra quantidade de entorpecente naquele recinto, local onde foram encontradas outras 26 (vinte e seis) porções de “crack”, além de 64 (sessenta e quatro) invólucros de cocaína, sendo certo que as embalagens de crack eram correspondentes. Ante as circunstâncias dos acontecimentos, coube ao depoente proferir voz de prisão em flagrante e identificar o preso sobre seus direitos constitucionais. As pesquisas levadas a efeito evidenciaram que ele registra antecedentes criminais pela prática de crime de idêntica natureza no passado, além de diversos furtos, sendo egresso do sistema prisional no final do ano de 2020”. Em juízo confirmou sua versão. Acrescentou que o acusado admitiu informalmente a prática do tráfico de entorpecentes e que as substâncias encontradas em sua casa e no interior do imóvel estavam embaladas de forma idêntica. Assim, a grande quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, juntamente com a apreensão de dinheiro, somadas às circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam o comércio ilícito. De fato, o réu foi apreendido na posse de considerável quantidade de drogas e de dinheiro. Outrossim, confessou em Juízo que guardava parte das drogas para terceiros. Neste panorama, devidamente demonstrados os fatos descritos na denúncia. Diante do acima exposto, requer-se a procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da incoativa. Na aplicação da pena há que se observar que o réu é multirreincidente, inclusive específico (certidão a fls. 127/133), razão pela qual não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

Outrossim, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, de acordo com as normas legais, e porque o crime de tráfico merece um grau maior de reprovabilidade, pois causa sérias consequências no meio social, notadamente no meio familiar, fomentando o uso indiscriminado de entorpecentes e, conseqüentemente, a prática de outros crimes pelo usuário, como pequenos furtos e roubos, os quais são praticados com o escopo de sustentar o seu vício. Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que reconhecida a impossibilidade de ser aplicado o redutor pelas razões antes mencionadas, a pena suplantará 04 anos, bem como o crime em questão é de elevada gravidade, o que demonstra não ser a medida socialmente adequada. Por fim, uma vez que comprovado que o dinheiro apreendido era oriundo do comércio de drogas, o Órgão Ministerial requer que seja decretada sua perda.

Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), foi dito o seguinte: MM. Juiz(a). PAULO SÉRGIO ALVES BAPTISTA vem processado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, conforme os fatos narrados na inicial acusatória. Após o recebimento da denúncia, a ação penal teve seu regular trâmite e a instrução foi encerrada na presente audiência. Em suas alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Ocorre, contudo, que a pretensão ministerial não encontra guarida, devendo a ação penal ser julgada improcedente. Com efeito, segundo consta, o apelante foi preso em flagrante após sofrer abordagem de guardas municipais, que teriam suspeitado de sua conduta. E indagados sobre as circunstâncias que antecederam a prisão do acusado, os guardas municipais Miranda e Macedo afirmaram que estavam em patrulhamento quando o avistaram saindo de um imóvel. Como ele demonstrou nervosismo, decidiram pela abordagem, que resultou na apreensão de uma garrafa de refrigerante contendo substâncias entorpecentes. Segundo os guardas municipais, o réu então admitiu a prática do tráfico e indicou que guardava mais drogas no imóvel do qual havia saído, onde então apreenderam mais porções de crack e cocaína. Ou seja, diante do apurado, forçoso convir que há irregularidades, que invalidam todo o caderno probatório produzido em desfavor do réu, sobretudo quanto a natureza da diligência realizada pelos servidores municipais. Ora, como se sabe, a teor do art. 144, § 8º, da CF, não é tarefa da GCM a investigação de infrações penais ou a prática de policiamento ostensivo para coibi-las. E, no presente caso, ficou demonstrado que os servidores municipais atuaram como se fossem integrantes das forças policiais, o que contraria o dispositivo constitucional supracitado. Com efeito, depreende-se dos depoimentos dos guardas municipais que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos (conhecido como "ponto de venda") quando decidiram abordá-lo em razão de atitudes suspeitas. Neste cenário, não se pode dizer que qualquer do povo poderia agir o que tornaria a prisão legal (art. 301, do CPP), já que a captura foi precedida de atos, cuja atribuição pertence a agentes policiais. Não é tarefa da GCM a prática de policiamento ostensivo e a realização de atos investigativos como busca e revista pessoal. Os agentes municipais não estão autorizados a efetuar patrulhamento ostensivo visando combater o tráfico de drogas. Neste sentido, destaco recente precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo: "Tráfico de Drogas - Abordagem do acusado em função típica de policiamento ostensivo por guardas civis municipais - Função típica reservada constitucionalmente à Polícia Militar - Não incidência do artigo 301 do Código de Processo Penal - Exorbitância dos poderes atribuídos no artigo 144, § 8º, da Constituição da República Federativa do Brasil - Prova ilícita - Absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal - Recurso da defesa PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1500260-53.2019.8.26.0546; Relator (a): Heitor Donizete de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021). Ainda que os guardas tenham agido com boa-fé, a questão é que eles não poderiam ir além da atuação autorizada a qualquer do povo, nos termos da legislação processual penal. E, reitere-se, não se vê qualquer cidadão praticando os atos que os guardas civis praticaram no caso sob exame. Na verdade, quando a lei permite a atuação de qualquer do povo em situação de flagrante delito, a intenção é a preservação do bem jurídico que está visivelmente sendo ofendido, o que não é o caso dos autos, em que o suposto crime

de tráfico só ficou demonstrado a partir de prévias diligências realizadas ilegalmente pelos servidores municipais. Além disso, cabe destacar que os guardas não tem competência para a prática de busca pessoa para apuração de possível ilícito penal. Não se trata de ato que não está dentro das atribuições dos guardas municipais, consoante Constituição Federal (art. 144) e Código de Processo Penal (art. 240 e seguintes). Sobre o tema, Gustavo Henrique Badaró assim ensina: "Há divergência sobre quem teria atribuição para realizar tais buscas. Não se discute sobre a possibilidade de a autoridade policial, federal ou civil, e de seus agentes realiza-las, até mesmo porque constitucionalmente lhes incumbe a atividade de polícia judiciária (CR, art. 144, § 1º, IV, e § 4º). Por sua vez, no caso de policiais militares, a matéria é controvertida. A polícia militar, embora tenha por finalidade a prevenção ao cometimento de crimes, também tem o escopo de atividade de imediata repressão aos delitos. Assim, não se pode conceber que, na atividade de policiamento preventivo e de imediata repressão a crimes que estejam ou acabaram de ser cometidos, o policial militar não possa, desde que respeitados os requisitos legais, realizar uma busca pessoal, havendo fundada suspeita de que alguém porta uma arma ou certa quantidade de droga. Por outro lado, há consenso no sentido de que os guardas municipais não podem realizar buscas pessoais. Por expressa previsão constitucional, cabem-lhes apenas a proteção de bens, serviços e instalações municipais, não lhes sendo atribuída nenhuma função de prevenção ou investigação de crimes". (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. p. 588). Assim, não há a menor dúvida de que a conduta dos guardas, na hipótese, acabou violando o art. 144, do CF, o que invalida toda a prova que foi produzida a seguir. Afinal, é evidente o nexo existente entre a revista pessoal e todos os elementos que deram suporte ao início da ação penal. Excluindo-se a busca ilegal, não haveria prisão, oferecimento da denúncia e início da ação penal. Logo, diante do todo exposto, requer-se o reconhecimento da ilicitude da ação policial e a consequente absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por pura falta de qualquer prova válida. Caso, no entanto, seja superada a questão sobre a invalidade das provas, a Defesa pugna pela absolvição do acusado em decorrência da fragilidade probatória. Isso porque a prova que o incrimina se resume aos depoimentos dos guardas municipais que o prenderam em flagrante. E nessa condição, evidentemente que seus testemunhos não podem ser considerados como totalmente isentos, pois há uma necessidade de justificarem seus atos, mormente porque o policiamento ostensivo e repressão de crimes não são atribuições da Guarda Municipal. Não se quer dizer que eles mentiram e que incriminaram o réu injustamente. Mas apenas que seus depoimentos não possuem a isenção necessária para, por si só, sustentarem uma condenação. Além disso, existindo apenas a prova oral, não se pode dar preferência ao depoimento dos servidores municipais em detrimento do interrogatório do acusado, o qual tem em seu favor a presunção de inocência. Assim, mostrando-se frágil o conjunto probatório, requer-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por fim, caso o entendimento de Vossa Excelência seja pela condenação da pessoa acusada, a Defensoria Pública pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, posto que não houve apreensão de quantidade expressiva de substância. Na segunda fase da aplicação da pena, observa-se que o acusado é reincidente, porém referida agravante deve ser compensada com a atenuante da confissão, uma vez que os responsáveis pela prisão do réu declararam que ele confessou o crime no momento da abordagem. Nesta audiência, ele renovou a confissão, admitindo que guardava drogas para um terceiro. A atenuante deve neutralizar a reincidência. Já na terceira etapa, requer-se a aplicação da causa redutora de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que não há provas de que o réu é integrante de organização ou associação criminosa, o que fica demonstrado pela ínfima quantidade de droga apreendida. Por fim, requer-se a fixação do regime inicial diverso do fechado.

A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a sentença a seguir:

Vistos,

PAULO SERGIO ALVES BAPTISTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,

porque, segundo a denúncia, no dia 28 de abril de 2022, por volta das 09h00, na Rua Tiradentes nº 892, Centro, nesta cidade e Comarca, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 16,5g de cocaína, distribuídos em 64 invólucros, 8,3g de cocaína na forma de pedra, distribuídos em 149 invólucros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que guardas municipais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, ocasião em que visualizaram o réu saindo de um imóvel em atitude suspeita. Em razão disso, abordaram-no e localizaram em sua posse 123 invólucros de crack e a quantia de R\$70,00, oriunda do narcotráfico. Em seguida, adentraram referido imóvel e localizaram em seu interior mais 26 invólucros de crack e 64 de cocaína, com as mesmas características daqueles encontrados em sua posse.

Conclui a denúncia que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à mercancia ilícita.

O réu foi notificado nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls. 143). Defesa preliminar apresentada às fls. 147. Após, a denúncia foi recebida (fls. 107/110) e o réu foi citado às fls. 185.

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada em comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, alegando estarem provadas autoria e materialidade do delito.

A Defesa pediu a absolvição, por falta de provas e arguindo ilicitude da ação dos guardas.

É o relatório.

Decido.

Afasto ainda a tese defensiva de que houve ilegalidade na ação dos guardas municipais e, conseqüentemente, nulidade da prova.

Os guardas municipais integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas municipais a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância.

Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Municipal a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Registre-se, ainda, que em 2014 foi sancionada a Lei 13.022/14, que dispõe acerca do Estatuto Geral das Guardas Municipais. Referido diploma legal institui normas gerais para as Guardas Municipais, disciplinando o artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

A Lei 13.022/14 constitui norma geral, aplicável a todas as leis municipais que tratarem sobre suas respectivas guardas, posto que cada Município deve editar a sua própria lei, adequando-se às disposições do Estatuto Geral das Guardas Municipais. A importância dessa Lei encontra-se no fato de que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal.

De fato, dispõe esta norma constitucional que "os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei". A interpretação restritiva encontra-se no fato de que as Guardas Municipais sempre tiveram um papel relacionado com a proteção do patrimônio municipal. A Lei 13.022/14 amplia a interpretação, estabelecendo que as Guardas Municipais podem colaborar com os demais Órgãos de segurança pública, no caso as Polícias Civil e Militar.

Isso se depreende das competências que a Lei confere às Guardas Municipais. O artigo 4º atribui a competência geral, qual seja, a proteção de bens, serviços,

logradouros públicos municipais e instalações do Município, conforme já previsto na Constituição Federal. Por outro lado, o artigo 5º adjudica as competências específicas. E é entre as competências específicas que podemos destacar que as Guardas Municipais não estão restritas à proteção do patrimônio municipal, mas também lhes são atribuídas funções de colaboração na apuração penal e defesa da paz social.

Outrossim, não cabe qualquer alegação de inconstitucionalidade da Lei 13.022/14, por ter este diploma conferido poderes às Guardas Municipais de atuarem em prol da segurança pública. Em primeiro lugar, as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública do Estado, razão pela qual se encontram em um dos parágrafos do artigo 144, da Constituição Federal. Em segundo lugar, a atuação das Guardas Municipais é sempre ligada às suas atribuições constitucionais (proteção do patrimônio municipal) ou, quando mais ampla, atuará em colaboração com os demais Órgãos de segurança pública (Polícias Civil ou Militar). Inclusive, é o que dispõe o artigo 5º, IV e parágrafo único, da Lei. Por fim, as Guardas Municipais, quando no exercício da sua competência, deverão obedecer às competências dos Órgãos Federais e Estaduais, prestando o auxílio necessário para a elucidação dos fatos. Pelo que se vê, as Guardas Municipais estão investidas na incumbência de garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de delitos, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência ou, no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso.

Ainda que assim não fosse, não haveria a alegada ilegalidade.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, bem assim que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Conforme revelou a prova que a seguir será analisada, o réu foi visto em situação suspeita da prática de crime, demonstrando intenso nervosismo ao notar a presença da guarnição e colocou a mão na cintura, como se quisesse segurar/ocultar algo, o que permitiu a ação dos guardas municipais que resultou no encontro dos entorpecents.

Registre-se que, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais.

Neste sentido, jurisprudências:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - Preliminar - Nulidade ante a abordagem ter sido realizada por Guardas Civis Municipais - Não ocorrência - Existência de justa causa para a realização da medida - Agentes que possuíam informação a respeito daquele veículo ser utilizado para abastecer o tráfico - Possibilidade para averiguação - Delito permanente, de modo que o acusado se encontrava em situação de flagrante delito - Mérito - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas - Fala dos agentes firmes e coerentes - Validade - Depoimentos que se revestem de fé-pública - Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu - Quadro Probatório seguro, estando apto a embasar um decreto condenatório - Pena e regime que não comportam alteração - Preliminar rejeitada e recurso desprovido". (TJSP. Apelação Criminal 1500184-29.2020.8.26.0567. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR EDISON BRANDÃO j. 05/10/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE EFETUADO POR GUARDA MUNICIPAL. VALIDADE. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte Superior, é possível que, diante de notícia criminis, envolvendo qualquer dos bens jurídicos mencionados, o agente municipal proceda à atividade de vigilância no local indicado para se certificar de sua veracidade, hipóteses nas quais, de nenhum modo, estaria desautorizado a agir. 2. A situação de flagrância delitiva legitima a atuação de "qualquer pessoa do povo" a proceder à prisão, oportunidade em que é perfeitamente possível a realização da abordagem do suspeito, não sendo diferente em relação àqueles agentes que, ao realizarem seu mister de zelar pelo patrimônio público, muitas vezes se deparam com infrações penais, sendo-

lhes lícito atuar em tais ocasiões. Precedentes. 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 4. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar que "foi efetuada a apreensão de uma balança de precisão, 01 tijolo de maconha e mais 144 (cento e quarenta e quatro) porções da mesma droga, acondicionadas em pequenas porções, próprias para venda", nos termos do acórdão a quantidade do entorpecente totalizou 782,9g. Ficou registrado, ainda, que o síndico do condomínio, relatou que "Charles Rogério Mendes Júnior é o responsável pela sala de energia, bem como detentor das chaves do local onde foram encontrados os entorpecentes" 5. A adoção de medidas cautelares diversas não é adequada na hipótese, diante da gravidade das condutas perpetradas (art. 282, II, do Código de Processo Penal), a denotar particular periculosidade do acusado. 6. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias". 7. No caso, não há comprovação de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja inserido em estabelecimento prisional superlotado. 8. Ordem denegada." (STJ - HC 583.610/SP. SEXTA TURMA. Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - j. 04/08/2020) g.n.

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexistente óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. Como é de conhecimento, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, constataram a presença da materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, de modo que a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 5. Nos termos do verbete n. 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que "a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância

pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". Assim, na hipótese, não há se falar em incidência da referida atenuante. 6. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 586.612/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA j. 25/08/2020) - g.n.

Afastada, dessa forma, a preliminar arguida pela defesa, passo à análise do mérito. A denúncia procede.

Autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelos seguintes elementos:

- 1) Boletim de ocorrência de fls. 07/09 c.c. 89/92;
- 2) Auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e fotografias de fls. 13/16;
- 3) Laudo de constatação de fls. 18/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 134/136, com resultados positivos para cocaína em relação às substâncias apreendidas;
- 4) Prova oral.

Vejamos:

Na fase informativa (fls. 04/05), o réu disse que era viciado em crack, cocaína e maconha e vivia na rua, sem endereço fixo. Alegou que já fez tratamento para tentar se livrar da dependência química e já foi preso por tráfico de drogas e furtos, encontrando-se, na data dos fatos, cumprindo pena em regime aberto. A respeito da imputação, invocou o direito de permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo (gravação), confessou o crime. Disse que morava na rua e, depois, passou a ocupar a casa situada no endereço indicado na denúncia. Um traficante lhe ofereceu R\$ 300,00 por semana para guardar drogas para ele. Assim, passou a esconder os entorpecentes na casa abandonada que habitava. No dia dos fatos, foi abordado pelos guardas, mas não portava drogas. Informou a eles que escondia entorpecentes no imóvel abandonado que usava para dormir, indicando-lhes exatamente onde os escondia (sob umas folhas no jardim). Assim, eles foram até lá e encontraram 3 pacotes com 26 pedras de crack cada um, que estava guardando para o traficante. Alegou que não havia cocaína.

A confissão foi corroborada pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 02) e em juízo (gravação), o guarda municipal Francisco Dernival Miranda Júnior declarou que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento de rotina pela área central da cidade, na companhia de seu colega Macedo, quando, na Rua Tiradentes, notaram a presença de um indivíduo que saiu de um imóvel e seguiu caminhando pela rua. Ao perceber a presença da guarnição, ele demonstrou intenso nervosismo e mexeu na cintura como se tentasse ocultar algo. Assim, resolveram abordá-lo. Em suas vestes íntimas, encontraram uma garrafa pet pequena, vedada por tampa, contendo 123 porções de crack. No bolso da sua bermuda, encontraram a quantia de R\$ 70,00, em cédulas de R\$ 2,00. O acusado admitiu a posse e propriedade do entorpecente e confessou que se destinava ao comércio ilícito, informando que o realizava numa praça existente nas imediações do terminal central de ônibus, sendo que estava a caminho daquele local com intuito de fazer as vendas. Ele, ainda, revelou que ocupava a casa de onde havia saído, a qual estava abandonada, e que lá guardava mais entorpecente, além de documentos pessoais. Assim, foram até lá e encontraram outras 26 porções de crack, embaladas de forma idêntica às que estavam na posse dele, além de 64 invólucros contendo cocaína. Elas estavam sob umas folhas, no jardim, no exato local indicado pelo réu. No mesmo sentido as declarações prestadas extrajudicialmente (fls. 03) pelo guarda municipal Juvenal Estevão de Macedo.

Anoto que os relatos dos guardas municipais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teriam procedido de má-fé. O próprio réu disse que nada tinha contra eles.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar suas palavras na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Confirmam-se alguns julgados:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS

VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

De fato, não se coaduna com a lógica probatória aceitar a alegação do acusado em detrimento da palavra dos agentes: enquanto o interesse destes é apenas relatar ocorrências registradas no cumprimento do dever de ofício, o daquele é eximir-se de sanção penal. Mas não há olvidar a significativa diferença entre ambos: apenas um deles tem o dever-jurídico de dizer a verdade.

Registro que os relatos dos guardas municipais não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

Diante desse quadro, não há dúvidas de que o réu trazia consigo e guardava para fins de tráfico 64 invólucros contendo cocaína e mais 149 invólucros contendo cocaína na forma de pedra, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, ele próprio admitiu o tráfico, ao declarar, nesta audiência, que guardava as porções de crack para um traficante em troca dinheiro.

A prova oral, entretanto, demonstrou o tráfico em maior extensão, ao demonstrar que parte das porções de crack estavam na posse do réu quando ele foi abordado na rua e outra parte na casa ocupada por ele, onde também havia mais 64 porções de cocaína, tudo para fins de tráfico.

O destino mercantil dos entorpecentes apreendidos ficou evidenciado não só pelas circunstâncias da diligência, mas também em razão da quantidade expressiva de drogas apreendidas, incompatível com a situação de mero usuário e pelo fato de estarem embaladas em porções individuais, como geralmente são comercializadas (fotografia de fls. 13/16).

Além disso, o réu ainda trazia consigo R\$70,00 em notas trocadas, cuja origem lícita não foi comprovada, o que, aliado ao fato de ele se declarar morador de rua e, portanto, sem emprego fixo, evidentemente era produto do ilícito penal.

Registro que, ainda que se considerasse a possibilidade de o acusado ser usuário de drogas, a condição de usuário não é inconciliável com a traficância, pois não é incomum usuários traficarem para sustentarem o próprio vício e ainda obterem algum lucro.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

“TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas - Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimento dos policiais que se mostraram coerentes e firmes. Mensagens que de whatsapp que não se mostraram o principal para configuração do crime. Apenas se somam aos depoimentos dos policiais. Utilizadas para confrontar o réu no momento da abordagem sobre a prática de tráfico de drogas, este admitiu e indicou onde estaria o restante das drogas. Quantidade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Desclassificação para o crime de porte de entorpecentes para uso próprio. Não acolhido. Ausência de comprovação de que fosse apenas usuário. De qualquer forma o ser usuário não esgota a condição de tráfico, cada vez mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício, adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. Dosimetria da pena. Mantida sem alteração. Regime mantido. Não recomendável mais abrandamento. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.” (TJSP - Apelação Criminal 0000106-69.2018.8.26.0603 - 3ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcante - J. 20/07/2020). g.n.

“MATERIALIDADE – Auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – Comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA – Depoimento de policiais que confirma a abordagem da ré e do menor, cujas características coincidiam com aquelas informadas em denúncia como sendo a dos traficantes, ocasião em que houve apreensão de drogas em poder do menor – Confirmação pelos policiais de que o adolescente afirmou que a ré trabalhava junto na traficância, na função de 'olheira' – Validade – Depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – Inocorrência no caso em tela. TRÁFICO – Destinação a terceiros – Quantidade incomum com a figura do usuário – Forma de acondicionamento das drogas, própria para a venda a varejo – Apreensão de dinheiro – Falta de condições econômicas para a ré possuir a droga para seu uso pessoal – Denúncia – De rigor a condenação da ré – Absolvição – Impossibilidade – Negado provimento ao apelo. CAUSA DE AUMENTO – Prática do delito que envolveu adolescente demonstrada pela prova oral – Causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configurada. PENA – Base fixada em 1/6 acima do mínimo legal – natureza da droga de alto potencial lesivo – Manutenção – Presente a atenuante da menoridade – Redução da pena ao mínimo legal – Súmula 231 do STJ – Presente a causa de aumento relacionada com o envolvimento de

adolescente - Exasperação da pena em 1/6 - Reconhecido o redutor na fração de 2/3 - Manutenção ante a inércia ministerial - Dedicção da ré à atividade criminosa - Passagem por ato infracional - Apreensão de considerável quantidade de droga - Profissionalização - Dedicção à atividade criminosa - Manutenção porque vedado a reformatio in pejus - Redução da pena - Impossibilidade - Improvimento ao apelo. REGIME - Fechado - Apreensão de elevada quantidade de droga - Natureza dos entorpecentes que possui alto potencial lesivo - Alta reprovabilidade e periculosidade - Ré que ostenta processo por ato infracional - O regime deve ser o necessário para dissuadi-los a retornar a delinquir (Beccaria) - Regime fechado - Necessidade - Improvimento ao apelo". (TJSP - Apelação Criminal 1502824-11.2019.8.26.0544 - 6ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Lauro Mens de Mello - J. 16/07/2020) g.n.

Portanto, pelas condições reveladas, imperiosa a condenação do réu pelo crime do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Passo à individualização das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não lhe são desfavoráveis, razão pela qual fixo as penas-base em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Reconheço a agravante da reincidência, inclusive específica (condenação no processo criminal nº 11145-44.2012, fls.128 c.c. fls. 63) e ainda por furto (condenação no processo nº 1500097-11.2019, fls. 130/131; nº 1500235-12.2018, fls. 131 e nº 1508200-63.2019, fls. 132).

Por outro lado, ele tem a seu favor a atenuante da confissão da autoria do crime. Como ambas as circunstâncias se compensam, deixo de aumentar ou diminuir as penas na segunda fase.

Inexistem atenuantes causas de aumento ou diminuição de penas.

Registro que, por expressa disposição legal, a reincidência, que inclusive é específica, impede a aplicação do redutor do parágrafo 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06 e impõe a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, sem possibilidade de substituição por restritivas de direitos ou concessão de sursis, pois indica que o réu vem reiterando na prática do crime em questão.

Acrescente-se a isso as graves consequências do delito de tráfico, que fomenta a prática de vários outros crimes, destrói famílias, vidas e a saúde dos usuários, que dificilmente conseguem se livrar do vício.

Eleição de regime diverso e aplicação de penas substitutivas da corporal, no caso concreto dos autos, impediriam que a pena cumprisse suas funções de prevenção e reprovação dos crimes, pois não fariam com que o réu, reincidente específico, sentisse as consequências de seu grave ato.

Há várias decisões de nossos Tribunais no sentido de que é possível a eleição do regime fechado, sem substituição por restritivas de direitos, em casos como esse. Confiram-se:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso da defesa - Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coesos depoimentos dos policiais militares bastam para a comprovação da mercancia ilícita - Tráfico bem caracterizado - Condenação mantida - Penas bem dosadas - Regime inicial fechado bem imposto, diante da gravidade concreta da infração penal e da reincidência específica do réu - Recurso defensivo improvido." (TJSP - Apelação 0037058-28.2016.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017).

"Apelação Criminal. Tráfico. Apreensão de 312 gramas de maconha, no interior de estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Pleitos de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da imputação para a rubrica do artigo 28, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Materialidade, autoria, culpabilidade e destinação mercantil, demonstradas pelo acervo coligido - Depoimentos de agentes de segurança penitenciária, seguros e sem contradições, cujo teor foi corroborado pela confissão judicial - Crime caracterizado que afasta a pretensão desclassificatória - Condição de usuária (sequer aventada pela ré) que não impede a prática do tráfico ilícito nem é suficiente para descaracterizá-lo -

Majorante configurada (crime perpetrado nas dependências de estabelecimento prisional) - Dosimetria - Reincidência (específica) e gravidade concreta do delito que obstam a aplicação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, e impõem o regime prisional fechado para o início da expiação - Condenação confirmada em 2º grau que exige a imediata expedição de mandado de prisão para o início da expiação - Precedente do STF (HC/SP nº 126.292) - Apelo defensivo, não provido, com determinação." (TJSP - Apelação 0016048-25.2016.8.26.0050. 5ª Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Juvenal Duarte - j. 31/08/2017) -g.n.

Registro que o reconhecimento da reincidência para fins de impedir a concessão de benefícios ao acusado e apená-lo de forma mais grave não fere a coisa julgada, nem constitui "bis in idem", pois não se trata de punir o agente duas vezes pelo mesmo fato.

Como bem ensina Guilherme de Souza Nucci, essa ideia "peca pela simplicidade. O sistema de fixação de penas obedece a outro preceito constitucional, merecedor de integração com os demais princípios penais, que é a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF)" (CPComentado - RT, 13ª ed., pag. 464).

Ao se reconhecer a reincidência e aumentar a pena do crime em razão dessa agravante ou deixar de aplicar ao réu alguma benesse, o Estado nada mais faz do que punir com maior rigor o agente que, tonando a delinquir, desafia a ordem pública e as leis vigentes, demonstrando, no dizer do professor Nucci, "persistência e rebeldia inaceitáveis para quem pretenda viver em sociedade. Destarte, sofre uma punição mais severa" (obra citada, pag. 464).

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico.

APELAÇÃO CRIMINAL - PENA E REGIME PRISIONAL - Pena fixada com critério e corretamente - Reincidência do réu que inviabiliza a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - Bis in idem não caracterizado, pois o aumento na segunda etapa e a impossibilidade de aplicação do privilégio na terceira fase são efeitos distintos decorrentes do mesmo instituto - Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de sursis, por força do disposto nos artigos 44, incisos I e II, e 77, caput, e inciso I, ambos do CP - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recurso desprovido." (TJSP - Apelação 0003941-43.2015.8.26.0127 - 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Nelson Fonseca Junior - j. 14/09/2017) -g.n.

Anoto que não é cabível a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, porquanto o réu está preso há pouco mais de três meses, não tendo, ainda, preenchido o requisito objetivo para progressão de regime.

Cada dia-multa terá o valor mínimo legal, diante da ausência de elementos para se verificar as condições econômicas do réu.

Diante do exposto e de tudo